

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA XII

EMPRESAS ESTATAIS

No que diz respeito às empresas estatais, é fundamental estar atento ao art. 173 da Constituição Federal.

Constituição Federal de 1988

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a **exploração direta de atividade econômica** pelo Estado **só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo**, conforme definidos em lei.

§ 1º **A lei** estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias **que explorem atividade econômica** de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

A própria Constituição Federal autoriza que existam situações excepcionais. Assim, ressalvado o que ela dispuser ao longo de seu texto, a exploração direta de atividade econômica corresponde ao Estado. Ou seja, o Estado desempenha essa atividade econômica por meio de suas empresas estatais. Nesse ponto, em provas, quando forem mencionados termos como “só”, “somente”, “apenas”, “sempre” e “desde que”, o candidato já supõe que deve haver alguma exceção.

Todavia, o termo “só” está explícito no art. 173 da Constituição Federal. Logo, é essencial salientar que o texto constitucional limita o Estado, definindo que não o permite explorar atividade econômica, salvo nos casos em que ela mesma estabelecer. Nesse sentido, observe que se colocar o Estado o tempo inteiro explorando a atividade econômica, ele não estará no mesmo patamar de um particular, pois possui diversos privilégios e prerrogativas. Logo, não haveria a livre competição e a livre concorrência.

Vale mencionar que o art. 174 da Constituição Federal discorre sobre os princípios da liberdade econômica e os princípios do mercado, como a livre iniciativa e a livre concorrência. Dessa forma, não é possível em todos os casos haver livre concorrência estando, de um lado, o particular, e, de outro lado, o Estado. Por isso, a Constituição Federal não deseja que o Estado explore atividade econômica, pois está em um patamar superior. Entretanto, quando o Estado, em algumas situações, desempenhar esse papel, ele desce de patamar e se iguala na posição de particular. Assim, quando o Estado estiver explorando atividade econômica, ele se valerá das chamadas empresas estatais.

ANOTAÇÕES

A primeira possibilidade de o Estado desempenhar atividade econômica é quando essa for necessária aos imperativos da segurança nacional. Ou seja, uma situação em que o Estado precisa intervir, desempenhando exploramos econômica, porque está relacionada à segurança nacional. Por exemplo, situações que podem gerar risco à soberania e à sociedade caso ele continue, de repente, tendo que importar e comprar produtos de fora do Brasil. Diante dessa situação, o Estado passa a produzir, pois, internamente, ninguém deseja produzir, uma vez que o risco é muito significativo e o prejuízo é quase uma certeza.

A segunda situação em que o uma atividade econômica pode ser explorada pela Estado é quando houver relevante interesse coletivo. Observe que se está em uma situação diferenciada, que é detalhada no art. 173, § 1º, da Constituição Federal.

De acordo com o art. 173, § 1º, da Constituição Federal, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de sua subsidiária. O dispositivo se refere a Lei n. 13.303/2016, conhecida como o Estatuto das Estatais, pois o artigo define justamente que a lei estabelecerá o estatuto jurídico delas. Logo, o Estatuto das Estatais, ou seja, o estatuto jurídico, é a Lei n. 13.303/2016.



ATENÇÃO

Em relação a provas, em regra, não é preciso conhecer a Lei n. 13.303/2016, salvo se o edital expressamente mencionar. No entanto, alguns dispositivos dessa lei, são obrigatórios, como a parte conceitual e algumas características. Sendo assim, será preciso conhecer o detalhamento e suas minúcias apenas quando aparecer expressamente no edital. É por essa razão que se trata a lei das estatais separadamente.

Além disso, é importante destacar que o art. 173, § 1º, da Constituição Federal esclarece que haverá a incidência do Regime Jurídico de Direito Privado. Contudo, há um ponto em especial no art. 173, § 1º, que reforça a incidência majoritária e predominante do Regime Jurídico de Direito Privado. Perceba que o dispositivo não está se referindo a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse caso, em específico, faz referência a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica.

ANOTAÇÕES



Nesse momento, surge o questionamento em relação aos Correios. Sobre isso, vale enfatizar que existem estatais que, de maneira equivocada, irão nascer para prestar serviço público típico essencial do Estado. No entanto, para essas, também se destina um tratamento diferenciado.

Por exemplo, é possível que uma empresa pública ou sociedade de economia mista desempenhe o poder de polícia na função de aplicar sanção ou para aplicar uma multa. A regra é que não se permite, já que empresa pública e sociedade de economia mista exploram atividade econômica. Todavia, se ela nasceu para prestar esse serviço público específico, altera-se a linha de raciocínio.

Outro caso, a BHTrans é uma sociedade de economia mista e pode aplicar multa de trânsito, pois o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu dessa forma. A razão disso, é que ela é diferenciada, ou seja, não é como uma empresa pública qualquer. Sendo assim, as empresas públicas ou sociedades de economia mista que são ímpares devem ser destacadas, no sentido de retirar da regra geral. Logo, não se pode afirmar que empresa pública e sociedade de economia mista pode aplicar multa. Contudo, pode-se afirmar que, excepcionalmente, isso é possível.

No que tange ao Correios, esses prestam um serviço público essencial, o chamado serviço postal, que é de competência privativa da União. Nesse caso, o STF tomou a decisão de colocar os Correios no patamar diferenciado. Assim, quando se tratar de modo geral, responda de modo geral, e se tratar de modo específico, siga a especificidade. Lembrando que, a regra é que a empresa pública e a sociedade de economia mista explorem atividade econômica e, por isso, há incidência predominante do Regime Jurídico de Direito Privado. É relevante frisar que, aquelas que nascem para prestar serviços públicos, terão uma maior incidência do Direito Público.

Outro detalhe importante do art. 173, § 1º, da Constituição Federal é que o dispositivo especifica a exploração atividade econômica, nesse caso, primeiramente, envolvendo a produção ou comercialização de bens. Logo, é possível que haja uma sociedade de economia mista que produza bens, assim como pode existir uma sociedade de economia mista que comercializa bens.

A outra possibilidade está relacionada a produção ou comercialização de prestação de serviços. Ou seja, é possível produzir o bem, comercializar o bem ou prestar um serviço. Desse modo, se está explorando a atividade econômica de prestação de serviço. Porém, esteja atento, não se refere a serviço público. Por exemplo, a empresa pública ou a sociedade

ANOTAÇÕES



de economia mista não produz ou comercializa um bem, e sim, vende um serviço ou uma atividade. Sendo assim, o art. 173, § 1º, estabelece que pode-se produzir ou comercializar bens ou, ainda, pode-se comercializar a prestação de serviço.

Perceba que o art. 173, § 1º, da Constituição Federal apresenta diretrizes para que o Estatuto das Estatais, isto é, a Lei n. 13.303/2016, possa dispor sobre o previsto nos incisos desse dispositivo.

I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (...)

IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

Vale destacar que, conforme art. 173, § 1º, inciso I, da Constituição Federal a função social de uma empresa estatal é justamente a busca de receita e de lucro. Ou seja, explorar atividades produzindo bens, prestamos serviços e vendendo a prestação de serviço para que consiga receita. Depois, o que for arrecadado será alocado para a sociedade, utilizando para fins sociais.

Quanto a forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade natural, lembre-se que existem empresas estatais que integram a administração e, obviamente, precisam ser controladas. Logo, essas serão controladas tanto pelo Estado, como também pela própria sociedade, que está cada vez mais participativa das medidas administrativas.

Em relação ao art. 173, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal, vale recordar que, ao estudar a Lei n. 13.303/2016, nota-se que os conselhos serão compostos por membros com mandatos. O objetivo é oferecer mais rigidez para as empresas estatais, para que não haja a influência e ingerência tão grandiosa que aconteceu e acontece rotineiramente, como, se não atender aos interesses partidários de determinado grupo, ele será mandado embora.

II – **a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas**, inclusive quanto aos direitos e obrigações **civis**¹, **comerciais**², **trabalhistas**³ e **tributários**⁴;

A informação mais importante do art. 173 da Constituição Federal está no § 1º, inciso II. Nesse dispositivo, se traduz a ideia do Regime Jurídico de Direito Privado. De acordo com o inciso, as empresas estatais estarão submetidas, ou seja, sofrerem a incidência, do mesmo regime jurídico próprio das empresas privadas.



ANOTAÇÕES

Esteja atento ao termo “inclusive”, pois, em prova, o examinador o troca por “salvo” ou “exceto”. No entanto, o art. 173, § 1º, inciso II, utiliza o termo para reforçar que as empresas estatais estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas em relação aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

1. Obrigações civis: Registro para criação; responsabilidade civil das empresas privadas (regra geral) etc.

Há um tópico do Direito Legislativo chamado de Responsabilidade Civil do Estado, previsto no art. 37, § 6º. O dispositivo apresenta um regramento significativamente diferente, o qual se aplica para as Pessoas Jurídicas de Direito Público e para Pessoas Jurídicas de Direito Privado prestadoras de serviços públicos. Em regra, o Responsabilidade Civil do Estado não vale para as empresas estatais.

2. Obrigações comerciais: “Incidência de normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão” (art. 7º da Lei n. 13.303/2016).

O Art. 7º da Lei n. 13.303/2016 discorre sobre a incidência do Direito Comercial e Direito Empresarial para as empresas estatais. Inclusive, a própria Lei n. 13.303/2016, estabelece a necessidade de incidência das regras sobre a sociedade anônima. Sobre isso, lembre-se que, quando se trata de regras comerciais, há a situação da Lei de Falências, a Lei n. 11.101/2005. Nesse ponto, vale citar que a Lei de Falências é voltada para Pessoas Jurídicas de Direito Privado, ou seja, pessoas que, por apresentarem um déficit gigantesco, comparado com o que têm de crédito, quebraram.

Diante disso, surge o questionamento sobre a possibilidade de aplicação a Lei de Falências para as empresas públicas e sociedades de economia mista, já que deve-se aplicar as regras comerciais. Nesse contexto, especificamente, a Lei de Falências já exclui empresa pública e sociedade de economia mista da sua aplicação. Assim, se as empresas públicas e sociedades de economia mista forem “falir”, o instituto não será chamado de falência. Nesse caso, elas serão extintas e, para isso, depende de autorização legislativa. Sendo que, em regra, para extinguir pode ser por meio de lei ordinária genérica, não havendo a necessidade de lei específica.

ANOTAÇÕES



Com isso, as empresas públicas e sociedades de economia mista serão extintas, porém, não se denomina propriamente falência, pois não segue a Lei de Falência. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, discorda um pouco desse entendimento. Entretanto, a ideia que ele defende de que seria possível a adoção da Lei de Falência não é adotada. Dessa forma, não se aplica a Lei de Falência para empresas públicas e sociedades de economia mista, embora tenham que seguir regras comerciais próprias das empresas privadas.

3. Obrigações trabalhistas: Regime “celetista” para seus empregados (exceto para os administradores).

V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores;

No que diz respeito as obrigações trabalhistas, vigora o chamado regime celetista para seus empregados, exceto para os administradores. Lembre-se que os administradores são aqueles que ocuparão os mandatos e que farão parte dos conselhos, assim, há regramento especial e diferenciado para eles. Sendo assim, pode-se afirmar, de maneira genérica, que os empregados das empresas estatais são celetistas.

Nesse ponto, surge dúvida sobre se é possível afirmar que as empresas estatais seguem um regime jurídico único, porque podem usar somente o celetista. Todavia, esteja atento, pois o regime jurídico único está vinculado a Pessoas Jurídicas de Direito Público, já que para essas, há a necessidade de se escolher um único, porém, tem opção entre o estatutário e celetista. Portanto, adotou-se o regime jurídico único, no sentido de ser preciso escolher um único regime dentro desses dois. Desse modo, cabe à entidade federativa, a União, ao estado, ao Distrito Federal e aos municípios, escolher qual dos dois, pois deve ser único.

Para as empresas estatais, não se discute sobre um regime jurídico único, porque não tem escolha. Quando se trata de regime jurídico único é porque deve-se escolher entre um ou outro. Já para empresas estatais, há uma imposição, logo, precisam seguir o regime celetista. Vale mencionar que, apesar de serem são celetistas, precisam fazer concurso público.

- 4. Obrigações tributárias: Vide art. 173, § 2º.

Art. 173. (...)

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

ANOTAÇÕES



No que tange obrigações tributárias, é necessário estar atento ao art. 173, § 2º, da Constituição Federal, pois, frequentemente é cobrado em provas e pode induzir ao erro. De acordo com o dispositivo, as empresas públicas e sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais somente se o setor privado também tiver. Nesse sentido, lembre-se que as empresas públicas e sociedades de economia mista seguem um Regime Jurídico de Direito Privado, logo, não há motivo para gozar de privilégios fiscais ou ter imunidade tributária, caso contrário, haverá um descompasso com o setor privado.

No entanto, não significa que as empresas públicas e sociedades de economia mista jamais terão imunidade tributária. Observe que, conforme Constituição Federal, a regra é não ter o tratamento tributário diferenciado. Contudo, se o setor privado tiver, elas terão também. Por exemplo, foi editada uma medida estabelecendo uma alíquota tributária zerada, isto é, o governo federal zerou a alíquota tributária. Consequentemente, essa medida valerá para a empresa privada e para a empresa pública e sociedade de economia mista. Sendo assim, trabalha-se na mesma linha, diferente das autarquias, as quais possuem imunidade tributária, independentemente da iniciativa privada ter. A razão disso é que as autarquias são Pessoas Jurídicas de Direito Público, naturalmente, elas têm um tratamento diferenciado.

Retomando aos Correios, é importante recordar que eles foram tratados de maneira diferenciada e não seguem propriamente as regras dispostas no art. 173 da Constituição Federal. Dessa forma, embora seja uma empresa pública e, portanto, já está Regime Jurídico de Direito Privado, os Correios foram criados para poder prestar um serviço considerado essencial. Além disso, o STF definiu que, por prestarem um serviço postal, que é privativo da União, os Correios serão tratados de maneira diferenciada. Nesse sentido, vale citar que os Correios possuem imunidade tributária, porém, porque são os Correios, e não, porque são empresa pública. Ou seja, esteja bastante atento, pois o art. 173, § 2º da Constituição Federal apresenta a regra, mas existem exceções.

A imunidade recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, alínea 'a', da Constituição Federal (CF), não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município (STF – RE 594015/DF, julgado em 6/04/2017 – Informativo 860).



Por exemplo, conforme o RE 594015/DF do STF, se há uma empresa privada que está arrendando um imóvel público, esse que teria a imunidade. Logo, por ser uma empresa privada, não haverá essa imunidade. Sendo assim, se a empresa privada não tem a imunidade, a empresa pública e sociedade de economia mista também não terão, pois trabalham na mesma linha de raciocínio.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (FGV/2018/PREFEITURA DE NITERÓI-RJ/AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/CONTROLADORIA) A Lei Federal XX dispôs: Art. 1º. As empresas públicas que exploram atividade econômica seriam amparadas por cláusulas exorbitantes nas obrigações comerciais que viessem a assumir; Art. 2º. As empresas públicas que exploram atividade econômica teriam privilégios fiscais não extensivos às do setor privado; Art. 3º. As empresas públicas que exploram atividade econômica estariam sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto às obrigações trabalhistas. À luz da sistemática constitucional afeta à ordem econômica e financeira:
- a. apenas o Art. 1º é constitucional.
 - b. apenas o Art. 2º é constitucional.
 - c. apenas o Art. 3º é constitucional.
 - d. apenas o Art. 1º e o Art. 2º são constitucionais.
 - e. apenas o Art. 1º e o Art. 3º são constitucionais.



COMENTÁRIO

Lembre-se de que cláusulas exorbitantes são cláusulas diferenciadas de privilégios e prerrogativas. Além disso, as empresas públicas não que exploram atividade econômica não possuem privilégios fiscais não extensivo ao setor privado. No entanto, elas estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto às obrigações trabalhistas.

GABARITO

1. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.